



\* \* \* \* \*

## PREMESSA IN FATTO

### 1. L'avviso di accertamento esecutivo.

Con **avviso di accertamento esecutivo** n. 2 del 6.02.2025 (**doc. 1**), a firma del Responsabile del settore finanziario e tributi, notificato via p.e.c. il 15.02.2025 (**doc. 2**), il Comune di Berbenno, ha intimato a Vodafone Italia S.p.A. (di seguito Vodafone), di pagare entro sessanta giorni la somma complessiva di € **7.173,00**, con la seguente specifica:

- quanto a € 800,00 a titolo di “*canone unico patrimoniale*” per l’anno 2021;
- quanto a € 830,40 a titolo di “*canone unico patrimoniale*” per l’anno 2022;
- quanto a € 924,24 a titolo di “*canone unico patrimoniale*” per l’anno 2023;
- quanto a € 929,79 a titolo di “*canone unico patrimoniale*” per l’anno 2024;
- quanto a € 3.484,43 a titolo di “*sanzione amministrativa pecuniaria*”, fissata in misura pari al canone non versato per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024;
- quanto a € 204,43 per interessi, decorrenti dalla scadenza di ciascuna annualità del canone unico patrimoniale.

Nella sezione “motivazione dell’atto” viene precisato che il canone sarebbe dovuto “*per l’utilizzo in via mediata della rete di proprietà del soggetto titolare della concessione*” e, dunque, a prescindere dall’esistenza di un’occupazione e indipendentemente dall’utilizzo materiale dell’infrastruttura.

Inoltre, ai sensi dei commi 792 e ss. dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, che disciplinano l’avviso di accertamento esecutivo, l’atto avvisa della propria idoneità ad acquistare “... *efficacia di titolo esecutivo*”.

### II. La richiesta di autotutela.

Ricevuto tale avviso di accertamento Vodafone, con motivata istanza di autotutela del 4.3.2025 (**doc. 3**), ha rappresentato di non essere soggetta al pagamento di

alcun canone di occupazione, non essendo concessionaria di suolo pubblico nel territorio comunale, né titolare di una propria rete fissa, con conseguente applicazione dell'art. 5, comma 14-*quinquies* del D.L. n. 146/2021 (conv. con L. n. 215/2021) che ha autenticamente interpretato l'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 per precisare che il canone deve essere versato dal concessionario dell'infrastruttura (nel caso di specie TIM e, dal 2024, Fibercop) anche per le utenze delle c.d. società di vendita (tra cui Vodafone) che, come pacifico, non utilizzano materialmente l'infrastruttura.

Tale istanza è stata tuttavia respinta dal Comune di Berbenno con nota prot. n. 1910 del 13.03.2025 (**doc. 4**), nella quale si è sostenuto che l'applicazione del canone a titolo di c.d. occupazione mediata prescinderebbe dall'utilizzo "materiale" dell'infrastruttura, nonostante il richiamato comma 831 preveda espressamente il requisito dell'"*utilizzo materiale*" dell'infrastruttura stessa.

Di qui la presente impugnativa, confortata dalla suddetta norma di interpretazione autentica e dalla giurisprudenza che già si è espressa su numerosi casi analoghi per escludere che la mera Società di vendita sia soggetto passivo del canone.

\* \* \*

L'avviso di accertamento esecutivo è nullo, illegittimo ed erroneo per i seguenti

### **MOTIVI**

#### **(I)**

**FALSA APPLICAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 831, DELLA LEGGE 160/2019 COME AUTENTICAMENTE INTERPRETATO. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. INSUSSISTENZA DI RAPPORTI CONCESSORI CON IL COMUNE. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI VODAFONE.**

L'avviso di accertamento viene impugnato per insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, come interpretato

dall'art. 5, comma 14-*quiquies* del D.L. n. 146/2021, convertito con Legge n. 215/2021, e per difetto di legittimazione passiva di Vodafone.

Infatti, il servizio pubblico di telefonia fissa è erogato da Vodafone nel Comune di Berbenno senza una propria rete e senza propri apparati collocati sul territorio. Pertanto, non si realizza il presupposto della occupazione di suolo pubblico, che consentirebbe di applicare anche nei suoi confronti il canone patrimoniale unico. Vodafone, dunque, da un lato, come pacifico, non è titolare di alcuna concessione di suolo pubblico; dall'altro lato, come pure è pacifico, non è occupante abusiva e pertanto non ha ragione di richiedere il rilascio di una concessione di suolo pubblico a proprio nome.

\*

### **I.1 Riferimenti normativi: l'art. 1, co. 831, e l'interpretazione autentica.**

L'art. 1 della **Legge n. 160/2019** (Legge di Bilancio 2020), ai commi 816 e ss., ha previsto l'istituzione da parte dei Comuni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, **c.d. canone unico patrimoniale**, che, a decorrere dal 2021, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e altri prelievi similari, e ha stabilito (comma 819) che “*il **presupposto del canone** è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva...”.*

Il successivo **comma 831**, nel testo ora vigente, ha poi stabilito:

*“Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e*

*dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:*

| Classificazione dei comuni    | Tariffa   |
|-------------------------------|-----------|
| Comuni fino a 20.000 abitanti | euro 1,50 |
| Comuni abitanti oltre 20.000  | euro 1    |

*In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente **non può essere inferiore a euro 800**. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete”.*

Il **comma 831** ha formato oggetto di **interpretazione autentica**, ad opera del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, il cui art. 5, comma 14-quinquies, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, dispone:

*“Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:*

*a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una **separazione**, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, **tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale**, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, **il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture**, in base alle utenze delle predette società di vendita”.*

Insomma, a fronte di un apparente contrasto tra il concetto di occupazione “in via mediata” e il pur necessario presupposto dell’ “utilizzo materiale” delle infrastrutture, si è espressamente precisato che, quando il soggetto che fornisce il servizio all’utenza si avvale di infrastrutture altrui, cioè opera in forza di contratti intercorsi con il titolare dell’infrastruttura, è quest’ultimo che, quale concessionario, rappresenta l’unico soggetto passivo del canone patrimoniale.

È questo il caso di specie, come ora si vedrà.

## **I.2 Il servizio espletato da Vodafone e modalità tecnico-contrattuali di erogazione del servizio nel territorio comunale.**

Vodafone è titolare di licenze individuali e di autorizzazione generale per la prestazione del servizio pubblico di comunicazione mobile e fissa e per l'installazione delle relative "reti".

Il servizio pubblico di telecomunicazioni per la c.d. rete fissa è esercitato da Vodafone sia attraverso impianti propri che mediante convenzioni di servizio.

**Relativamente alla rete fissa**, Vodafone utilizza varie modalità e tecnologie per realizzare in concreto l'accesso, cioè la connessione tra componenti e/o apparati e/o infrastrutture della rete di Vodafone Italia (Rete Primaria) e l'utenza "fissa", ossia la presa telefonica del cliente.

Il servizio di rete fissa di Vodafone passa per una **distinzione fondamentale**:

- in taluni casi Vodafone realizza l'intero collegamento, tra la propria Rete Primaria, le proprie centrali e la "presa" del cliente, tramite una **propria Rete di Accesso**, ossia proprie centraline di diramazione e propri collegamenti in cavi di fibra ottica, entrambi posti lungo le strade del territorio comunale; in questi casi, fa capo a Vodafone il collegamento completo tra la centrale Vodafone e l'abitazione del cliente;
- nella maggior parte dei casi, invece, il collegamento tra la "Rete Primaria" di Vodafone e la presa del cliente avviene attraverso l'utilizzo, parziale o completo, di **servizi per il collegamento e/o impianti e/o cavi e/o centraline forniti da altri soggetti** posti sul territorio comunale. Il principale soggetto che, tramite le proprie infrastrutture (centraline e cavidotti), fornisce servizi di collegamento Wholesale (all'ingrosso) in favore di altri operatori, è l'ex monopolista **TIM – Telecom Italia S.p.a.**

(che, a giugno 2024, come noto, ha ceduto a **FiberCop**), quale **titolare della maggior parte delle infrastrutture di rete fissa della c.d. “Rete di Accesso”**, cioè dei cavi posti lungo le strade che, diramandosi, entrano materialmente negli immobili degli utenti. In questi casi e relativamente alla occupazione del territorio comunale necessaria per collocarvi cavi e centraline, **TIM è** - ai sensi del comma 831 dell’art. 1 della L.160/2019 – **il titolare della concessione per l’occupazione del “territorio comunale”**, quest’ultimo comprensivo – secondo la definizione del precedente comma 819 – delle **“aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”**.

Insomma, **nella maggior parte dei casi, TIM (FiberCop) fornisce a Vodafone e agli altri operatori (detti OAO, Other Authorised Operators o anche OLO, Other Licensed Operators), attraverso i propri cavi e/o i propri cabinet** (gli armadietti di ricovero degli apparati di diramazione) **il servizio di collegamento all’utente finale**. Questo servizio di collegamento, a sua volta, può essere realizzato mediante tecniche diverse (VULA, NGA...)

In particolare, la modalità tecnica di collegamento può essere **BITSTREAM NGA** (*Next Generation Access*), tipologia di accesso che prevede che l’Operatore sia presente (non sul territorio, né nella centrale TIM) esclusivamente in un punto di raccolta collocato a monte; oppure può essere **VULA** (*Virtual Unbundled Local Access*), tipologia di accesso che prevede che l’Operatore sia presente (non sul territorio ma) esclusivamente nella centrale TIM con un apposito kit di consegna.

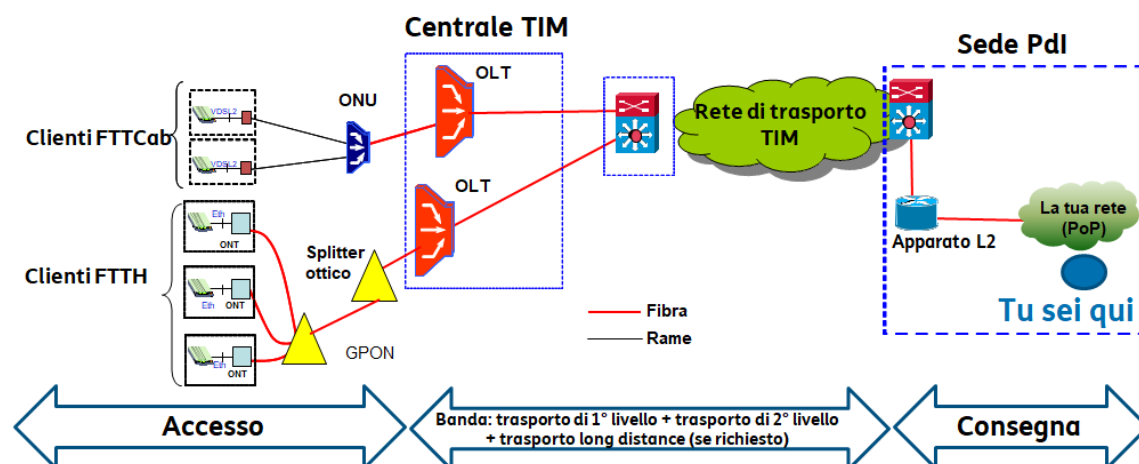
Con tali modalità di accesso, utilizzate anche nel territorio del Comune convenuto, Vodafone può offrire servizi di connessione (sia FTTC che FTTH) ai propri clienti senza essere presente con la propria rete né lungo le strade con propri cavi e cabinet e nemmeno nei cavi di diramazione che entrano negli immobili degli utenti (e, nel modello NGA, nemmeno nelle centrali TIM locali).

In altri termini, la connessione del cliente viene gestita da TIM e il traffico proveniente dalla Rete Primaria di Vodafone viene raccolto da TIM in un apposito punto di raccolta (PTO – Punto Terminazione Operatore o PDI – Punto Di Interconnessione) e poi collegato dalla stessa TIM mediante Fibra Ottica propria al Punto di Terminazione nella Centrale di Telecom (PTC/ODF - Optical Distribution Frame). La raccolta può avvenire sia a livello di area che di macroarea, cioè, approssimativamente, a livello di provincia o di regione.

Il servizio fornito da TIM (Fibercop) all'ingrosso (wholesale) è così descritto sul sito ufficiale ([https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/tw\\_servizi/bitstream-nga/](https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/tw_servizi/bitstream-nga/)):

*“Con il servizio regolamentato Bitstream NGA raccogliamo il traffico a larga banda dei tuoi Clienti, lo trasportiamo con la nostra rete e lo consegniamo alla tua rete a “livello 2” (Ethernet). Il servizio ha 3 componenti: consegna, banda, accesso. La consegna del traffico alla tua rete può avvenire a vari livelli di interconnessione, ma in ogni caso prevede che la tua rete si colleghi ad uno dei più di 500 punti della rete Telecom Italia abilitati alla consegna del servizio Bitstream (“Punti di Interconnessione” o “PdI”). Il collegamento tra il Pdi e la tua rete avviene tramite appositi apparati (“apparati L2”) che svolgono funzione di “confine” tra la rete Telecom Italia e la tua rete: l'apparato L2 e le porte che lo collegano al Pdi costituiscono il “Kit di Consegna”.*

Il seguente **schema esemplificativo** spiega l'architettura di distribuzione BITSTREAM NGA: l'operatore (Vodafone) è presente solo nella fase di consegna e si affida completamente a TIM sia per la distribuzione ed erogazione del servizio, sia quanto alla rete di trasporto (TIM) che collega la centrale TIM al Punto di Interconnessione.





L'Operatore (Vodafone) "affitta" l'intera tratta che va dal PDI alle abitazioni dei clienti, indipendentemente dall'architettura posta "a valle" della centrale (FTTC: *Fiber to the Cabinet* / FTTH: *Fiber to the House*). Infatti, sia nel caso di FTTC che di FTTH la fibra ottica trasporta il traffico di tutti gli operatori, separato tramite l'uso delle VLAN (Virtual LAN).

Questa modalità (BITSTREAM NGA) non va dunque confusa con l'ipotesi in cui la stessa Vodafone, pur appoggiandosi ad altro soggetto per il tratto finale, realizza una propria rete del tipo "Fiber to the Cabinet" (fibra fino agli armadi - FTTC), posando propri cavi telefonici interrati in fibra ottica nel tratto che intercorre tra la centrale Vodafone e ciascun "cabinet" (o armadio) su strada.

Si consideri che l'Operatore (Vodafone) stipula con il concessionario **contratti approvati dall'AGCom** che disciplinano le modalità di servizio, nonché le tecnologie di connessione che vengono utilizzate nei vari territori comunali in cui le utenze degli OAO (OLO) sono servite attraverso le infrastrutture di accesso (c.d. "ultimo miglio" – rete di accesso) nella titolarità di TIM (cfr. **doc. 5**, Brochure Wholesale TIM-Fibercop su servizi NGA).

Le descritte modalità tecnico-contrattuali sono notevolmente onerose per Vodafone, che è tenuta a compensare il fornitore dell'infrastruttura per il servizio di collegamento attraverso la Rete di Accesso, oltre che per il passaggio sulla rete di trasporto di questa (Rete Primaria). Vodafone, inoltre, non ha il controllo della rete di accesso né di parte della rete di trasporto, tanto che la manutenzione e la risoluzione dei guasti passa, di regola, da TIM, come da relative offerte.

In definitiva, la descrizione tecnica che precede consente di dimostrare:

- (i) che Vodafone non ha alcun impianto e/o infrastruttura della propria rete nel territorio comunale;
- (ii) che Vodafone non può definirsi utilizzatore "materiale" della rete di distribuzione, come richiesto dall'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019;

(iii) che alla fattispecie illustrata – avente fonte in assetti contrattuali - deve applicarsi la norma di interpretazione autentica, secondo la quale il concessionario (TIM-Fibercop) si fa carico degli oneri dell'occupazione di suolo pubblico anche per le utenze delle Società di vendita.

L'accesso all'infrastruttura del concessionario è dunque **virtuale**, perché l'operatore non dispone fisicamente e materialmente del collegamento, né tantomeno lo usa in esclusiva. Tale collegamento, trattandosi di “**collegamento virtuale**”, non integra la fattispecie di occupazione mediata di cui all'art. 1, comma 831, L. 160/2019 perché come recentemente ribadito “*l'art. 1, co. 831, nella sua nuova formulazione, prevede tuttavia che il Canone Unico sia dovuto dall'utilizzatore non concessionario soltanto là dove si configuri non una utilizzazione purchessia, ma una utilizzazione “materiale” delle infrastrutture... La mera utilizzazione di infrastrutture altrui non veicola di per sé una occupazione di territorio ulteriore, rispetto a quella già oggettivamente determinata dalla presenza delle infrastrutture. L'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro (mero) utilizzatore comporterebbe dunque la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo episodio di occupazione*” (**Trib. Vicenza, sent. n. 83 del 21 gennaio 2025, doc. 8**)

Ne deriva che l'impugnato Avviso di Accertamento Esecutivo non può legittimamente fondarsi sull'art. 1, comma 831, della Legge 160/2019.

### **I.3 Falsa applicazione dell'art. 1, comma 831.**

Per quanto sopra chiarito, l'**ipotizzata applicazione del comma 831 è erronea**, in quanto Vodafone non può essere annoverata fra i “... *soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione...*”.

Infatti, Vodafone, per un verso non è titolare di alcuna concessione di suolo pubblico; per altro verso nemmeno occupa, di fatto, aree di proprietà del Comune in questione.

Mancano, dunque, in radice i presupposti impositivi dell'art. 1, comma 823 della Legge n. 160/2019 (*“Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva”*).

Perché possa operare la pretesa economica da parte dell'Ente, dunque, vi deve essere un rapporto concessorio (che manca) ovvero un'occupazione, anche di fatto o mediata dalla interposizione di un'altra infrastruttura, di suolo o spazi pubblici; occupazione che in questo caso è assente.

A definitiva conferma di quanto precede l'**art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021** ha stabilito che il comma 831 deve essere interpretato nel senso che, ove sia riscontrabile una separazione tra il soggetto titolare del contratto di vendita (nel caso di specie, Vodafone) e il soggetto titolare dell'infrastruttura (nel caso di specie, TIM e, dal 2024, Fibercop), il primo non realizza né una “occupazione in via mediata” né un “utilizzo materiale” dell'infrastruttura, con la conseguenza che *“il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture”*.

Pertanto, richiedere il canone unico patrimoniale anche ai “soggetti titolari del contratto di vendita” quale è Vodafone nel caso che ci occupa, significa duplicare l'imposizione a ingiustificato vantaggio dell'Ente locale, posto che, per un verso, Vodafone è già legata al concessionario da rapporto contrattuale oneroso che già tiene conto degli oneri di occupazione di suolo pubblico e, per altro verso, **la soggettività passiva del concessionario espressamente ricomprende anche le utenze delle società di vendita.**

Il sistema delineato dal Legislatore, all'evidenza, non penalizza ma agevola l'Ente

concedente (e, parimenti, il concessionario per la riscossione) perché individua un unico interlocutore e soggetto passivo del canone unico patrimoniale, vale a dire il concessionario e, nello stesso tempo, tiene conto che il concessionario già si giova, nei propri rapporti con i meri titolari dei contratti di vendita, di canoni contrattuali la cui congruità è stata approvata dall'AGCom. TIM, infatti, riceve un corrispettivo più che indennitario per ciascuno degli utenti di Vodafone che viene connesso tramite la sua infrastruttura.

#### **I.4 Applicabilità della norma di interpretazione autentica al settore delle telecomunicazioni.**

Va precisato, per prevenire infondate obiezioni, che la norma di interpretazione autentica (art. 5, comma 14-*quinquies*, della Legge n. 160/2019) è certamente applicabile anche nel settore delle telecomunicazioni.

Già da un **punto di vista letterale**, l'inequivoco riferimento della norma di interpretazione autentica alle ipotesi di **separazione** (di fonte non solo legislativa e regolamentare, ma **anche contrattuale**) tra titolarità dell'infrastruttura e del contratto di vendita, consente di attrarre pacificamente alla fattispecie considerata anche ciò che si verifica nella fornitura di servizi di telecomunicazione.

La norma, pertanto, si applica in tutti i casi di fornitura in cui il titolare dell'infrastruttura non coincide con il titolare del contratto di vendita.

La **riprova** dell'applicabilità dell'art. 5, comma 14-*quinquies*, al settore delle telecomunicazioni **si rinviene nei lavori parlamentari**.

Il Dossier D.L. 146/2021 – A.C. 3395, infatti, nel presentare la norma, dopo aver premesso che “il comma 14-*quinquies* dell'articolo 5, inserito al Senato, contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di **servizi di pubblica utilità**, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi”

chiarisce che “**si tratta di servizi quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete**” (doc. 6, pagg. 59-61; pagg. 61-63 del pdf).

Inoltre, in sede di conversione del successivo **D.L. 228/2021** (recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”), sono stati presentati due **emendamenti**, che poi **non** sono stati **approvati**, che miravano proprio a escludere provvisoriamente il settore delle telecomunicazioni dall’applicazione dell’art. 5, comma 14-*quinquies*, sul presupposto logico scontato della omnicomprensività della norma stessa (**doc. 7**).

- Il primo emendamento non approvato è del seguente tenore:

**“Per il settore delle telecomunicazioni, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di concessione del suolo pubblico non abbia alcun rapporto diretto con l'utente finale ma si limiti, tramite la sua infrastruttura, a permettere ai soggetti titolari del contratto di vendita di distribuire il bene al cliente finale, l'interpretazione di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica fino al 31 dicembre 2022. Per tali soggetti, nell'anno 2022, il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro onnicomprensivi ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”**

- Il secondo e alternativo emendamento, non approvato, è del seguente tenore:

**“In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, fino al 31 dicembre 2022 l'interpretazione autentica si intende riferita esclusivamente ai settori dell'energia elettrica e del gas”. Limitazione dell'interpretazione autentica del canone unico ai settori dell'energia elettrica e del gas fino al 31/12/2022**

Tali emendamenti, ripetesi non approvati, sono l’evidente e inconfutabile riprova che l’art. 5, comma 14-*quinquies*, **trova applicazione anche nel settore delle telecomunicazioni**. La proposta di ritardare l’applicazione della norma al settore delle telecomunicazioni non è stata tuttavia approvata perché tali emendamenti non sono stati recepiti nella Legge di conversione del D.L. n. 228/2021, con conseguente esclusione della legittimazione passiva delle società di vendita.

\*\*\*

(II)

**IN OGNI CASO: DIFETTO DEL REQUISITO DELL'UTILIZZO MATERIALE RICHIESTO DALL'ART. 1, COMMA 831, DELLA LEGGE N. 160/2019. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA.**

**II.1** In ogni caso, anche a non voler considerare la norma di interpretazione autentica, comunque non ricorrono nel caso di specie presupposti impositivi della “occupazione mediata” e dell'utilizzo materiale delle infrastrutture, espressamente richiesto dal comma 831.

**II.2** Col termine “occupazione” si intende la “*sottrazione dell'area all'uso pubblico ed indifferenziato della collettività per destinarla ad un uso singolo e commerciale*” (TAR Lazio – Roma, sez. II-bis, 3 giugno 2021, n. 6533; analogamente Cass. Civ., V, 9 novembre 2021, n. 32869, secondo cui si ha occupazione, ai fini dell'applicazione delle norme TOSAP, quando si determini “*un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico*”).

L'occupazione, pertanto, presuppone una “**relazione materiale instaurata con la cosa**” da parte dell'occupante (cfr. Cass. Civ., sez. V, sent. 8 settembre 2017, n. 21018). Sul punto, Cass. Civ., ss.uu., 7 maggio 2020, n. 8628, ha ulteriormente precisato che la “*relazione materiale instaurata con la cosa*” è condizione necessaria e sufficiente perché possa parlarsi di occupazione di suolo pubblico, indipendentemente dall'esistenza e dalle caratteristiche di un titolo giuridico che giustifica l'occupazione stessa. Il punto è ribadito anche da Cass. Civ., sez. V, 16 novembre 2021, n. 34591.

Anche l'occupazione mediata richiede dunque una “*relazione materiale instaurata con la cosa*” che dovrà essere diversa dalla occupazione diretta, dovrà essere “mediata” dalla infrastruttura del concessionario, ma non potrà essere del tutto assente. Questo requisito è stato individuato, nel testo vigente, appunto con

l'indicazione per cui l'occupazione in via mediata avviene *“attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”*.

L'espressione “utilizzo” non può essere letta estensivamente; per un'elementare esigenza di coerenza sistematica, deve essere intesa in conformità con la nozione generale di “occupazione” (specificata al comma 819 ma rinvenibile nella complessiva disciplina di cui ai commi da 816 a 836, oltre che nella giurisprudenza sopra citata) e quindi deve ritenersi che richieda almeno la presenza stabile, sull'infrastruttura del concessionario, di oggetti materiali di cui l'occupante mediato abbia la disponibilità. Altrimenti, non si ha utilizzo materiale, bensì virtuale.

Per esplicitare un esempio concreto di *“occupazione mediata realizzata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”*, basti pensare all'utilizzo di un cavidotto di protezione (per rete idrica o rete elettrica o rete per telecomunicazioni o altro ancora) realizzato dal titolare della concessione del suolo pubblico (meglio sottosuolo) e che venga utilizzato anche per farvi passare e proteggere altro cavo elettrico o il cavo in fibra ottica di un altro soggetto. In questo caso si avrebbe un titolare della concessione che occupa il suolo pubblico e si avrebbe altresì una “occupazione mediata” dello stesso suolo attraverso l'**utilizzo materiale** del cavidotto.

Questa relazione materiale (mediata) fra gli impianti-cavi di un soggetto ed il territorio comunale si realizza frequentemente, ad esempio quando gli Enti provvedono a far concentrare e utilizzare congiuntamente talune infrastrutture come previsto, fra gli altri, dal D.Lgs. n. 33/2016.

In altri casi, nel settore delle telecomunicazioni, questa relazione si realizza quando gli operatori delle telecomunicazioni diversi dalla compagnia detentrici della rete installano propri apparati su infrastrutture del concessionario che occupano il suolo pubblico; in questi casi, l'infrastruttura del titolare della

concessione del suolo pubblico realizza il tramite-media fra il suolo e l'apparato dell'operatore terzo (occupante mediato).

La necessità di una relazione materiale trova conferma nella disciplina sanzionatoria delle occupazioni abusive laddove è prescritto (art. 1, comma 822) che *“gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni ... priv(e) della prescritta concessione o autorizzazione o effettuat(e) in difformità dalle stesse o per (le quali) non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone”*, con ciò dando per scontato che alla abusività corrisponde una materialità da rimuovere.

In definitiva, nel caso di specie, Vodafone non ha alcun materiale rapporto con le condutture, perché non ha la materiale disponibilità del collegamento, non può usarlo in modo esclusivo e non cura nemmeno la relativa manutenzione. È quindi semplice fruitore del servizio di rete fornito dal titolare della concessione sulla base di assetti contrattuali i cui schemi sono approvati dall'AGCom e le relative offerte pubblicamente disponibili sul sito “wholesale.telecomitalia” (cfr. in particolare: <https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/servizi/?tipo=servizi-di-accesso> e [https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/tw\\_servizi/vula/](https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/tw_servizi/vula/)).

**II.3** Ora, è agevole verificare che il Comune di Berbenno, preso atto che Vodafone non ha la titolarità della rete, pretende il versamento del canone anche da parte di Vodafone *“... per l'utilizzo in via mediata della rete di proprietà del soggetto titolare della concessione”* ma, a ben vedere, confessa di non aver tenuto conto del necessario requisito dell' *“utilizzo materiale dell'infrastruttura”*; tanto è vero che nell'avviso di accertamento, nella *“motivazione dell'atto”* precisa *“...senza che sia quindi necessaria alcuna occupazione fisica o modificazione della realtà”*. Risulta con ciò evidente che il Comune, disapplicando il comma 831, pretende il canone in difetto di un presupposto essenziale (utilizzo materiale) e, nel contempo, pretende di duplicare il canone per un'occupazione fisica che è in realtà unica.



**II.4** Ne consegue che, anche a voler prescindere dall'applicabilità della norma di interpretazione autentica (art. 5, comma 14-quinquies, D.L. n. 146/2021), non sussistono i presupposti impositivi di cui all'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, né quelli degli artt. 48, comma 8, e 51 del “Regolamento comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Berbenno n. 8 del 6.04.2021 (**doc. 16**), atteso che, per quanto chiarito, Vodafone non realizza un'occupazione permanente di suolo pubblico ulteriore rispetto a quella del titolare della concessione.

\* \* \* \* \*

#### (I-II)

#### **SUI NUMEROSI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI RESI SUL TEMA.**

E' importante ora dar conto che **altri avvisi di accertamento analoghi** a quello adottato dal Comune di Berbenno sono stati **annullati in sede giurisdizionale** in accoglimento di opposizioni formulate da Vodafone, con motivazioni basate su **duplice fondamento** ossia, da un lato, sulla valorizzazione della norma di interpretazione autentica, dall'altro lato, sulla accertata non ricorrenza nel caso di specie del requisito dell' “*utilizzo materiale dell'infrastruttura*”, espressamente richiesto dal comma 831.

In particolare, con la **sentenza 21 gennaio 2025, n. 83** (**doc. 8**), il **Tribunale di Vicenza**, in un caso perfettamente analogo, ha accolto la domanda di Vodafone precisando, quanto alla norma di interpretazione autentica, che:

“... si tratta di disposizione che si attaglia pienamente al caso di specie nel quale vi sono, da un lato, un soggetto (TIM) proprietario di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il Comune di Thiene e, dall'altro lato, un soggetto (Vodafone) che, sulla scorta di rapporti contrattuali intrattenuti con TIM, è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di TIM. A norma dell'art. 5, co. 14 quinquies del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, Vodafone, quanto all'anno 2021 qui in esame, non è dunque tenuta al pagamento al Comune di Thiene del Canone Unico di

cui all'art. 1, co. 831 della L. n. 160/2019”;

e, quanto al requisito dell' “*utilizzo materiale dell'infrastruttura*” che:

“Vodafone non ha materialmente utilizzato le infrastrutture del concessionario TIM presenti entro il territorio del Comune di Thiene – come sarebbe avvenuto se essa avesse materialmente posato proprie infrastrutture sul territorio comunale, così occupandolo a propria volta, “appoggiandosi” a quelle di TIM. Tanto non è accaduto nel caso di specie, nel quale (il dato è pacifico, come detto) Vodafone si è limitata a collegarsi in modo virtuale alle infrastrutture TIM”.

\*

La soluzione che si fa valere, pur nell'evoluzione del quadro normativo, è la stessa già motivatamente accolta da:

= **Cass. Civ. SS.UU., sent. 7 maggio 2020, n. 8628** che, in tema di TOSAP e COSAP, ha escluso la legittimazione passiva di soggetti diversi dal titolare della concessione posto che “il canone è dovuto dal concessionario e, solo in ipotesi di occupazione abusiva (cioè in mancanza di concessione), dall'occupante di fatto”;

= **Cons. Stato, sent. 12 aprile 2021, n. 2976** che, in un contenzioso intercorso tra il concessionario Telecom e la società di vendita Fastweb, ha precisato che “il canone previsto dalla legge era unico e riguardava il solo titolare della concessione e non i soggetti ospitati, nei cui confronti gli accordi con il titolare della concessione ben potevano tenere indenne quest'ultimo per la parte d'infrastruttura da essi utilizzata”;

= **T.A.R. Calabria, Catanzaro, sent. 12 aprile 2010, n. 451**, secondo la quale “per fini di semplificazione, i rapporti sono soltanto due: il rapporto tra l'amministrazione pubblica e il proprietario dell'infrastruttura; il rapporto tra quest'ultimo e gli operatori economici che accedono alla rete”;

= **Trib. Roma, Sez. II, sent. 3 luglio 2023, n. 10444**, che ha escluso la imposizione multipla in presenza di altri eventuali utilizzatori;

= in caso identico, **Trib. Padova, Sez. II, sent. 20 settembre 2023, n. 1802 (doc. 9)** che, quanto all'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021 ha osservato che:

“Vodafone è una società di vendita che opera in un settore ove è prevista la



agevola l'Ente concedente perché individua un unico interlocutore e soggetto passivo del canone unico patrimoniale, vale a dire il concessionario e, nello stesso tempo, tiene conto che **il concessionario già si giova, nei propri rapporti con i meri titolari dei contratti di vendita, di canoni contrattuali**, la congruità e modalità della cui quantificazione non è oggetto di questo giudizio. Certo è che è palesemente erroneo far discendere la soggettività passiva di Vodafone dalla mera titolarità di utenze (contratti di vendita) nel Comune, essendo tale presunto accertamento insufficiente e inidoneo a fondare la legittimazione passiva di Vodafone che, in questo caso, è positivamente esclusa dalla Legge".E ha aggiunto che una diversa interpretazione "...realizzerebbe un **contrasto col diritto comunitario** (art. 13 Direttiva 2002/20/CE e art. 42 Direttiva UE 2018/1972), posto che i contributi devono essere giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e giammai "duplicati" ...".

= ancora, **Trib. Perugia, sent. 5 luglio 2024 (doc. 11)** secondo la quale:

*"non risultano dubbi in merito al fondamento dell'opposizione avanzata da Vodafone Italia Spa che, nel caso concreto, come dalla stessa giustamente sostenuto, **difetta della presenza di infrastrutture materiali nel territorio del Comune** di Corciano e/o di concessioni da parte dello stesso Comune per l'istallazione di infrastrutture nel territorio del medesimo, mentre **intrattiene rapporti contrattuali con TIM** per la fornitura di servizi di telecomunicazione che, tuttavia, si svolge **senza il materiale rapporto con le condutture, che non sono occupate da materiali/cavi della Vodafone**, la quale, peraltro, non usa il collegamento in maniera esclusiva né si occupa della manutenzione, sostanzandosi - Vodafone Italia Spa - come nient'altro che una società di vendita".*

= sempre in caso analogo **Trib. La Spezia, sent. 21 marzo 2025** (che si produce sub **doc. 12**), secondo cui:

*"il servizio viene erogato mediante l'**accesso solo virtuale alla rete TIM** tramite tecnologia VULA, senza alcuna occupazione materiale del suolo pubblico... Questo tipo di utilizzo **non configura una occupazione mediata del suolo pubblico** e utilizzo materiale dell'infrastruttura, poiché la rete TIM è già soggetta a concessione, Vodafone non la utilizza per posare propri cavi all'interno della medesima e il canone è dunque interamente versato dalla proprietaria-occupante. E cioè la mera utilizzazione di infrastrutture altrui non importa di per sé un'occupazione ulteriore rispetto a quella determinata dalla presenza delle infrastrutture, salvo il caso in cui, come già anticipato, l'operatore telefonico non si sia limitato ad una utilizzazione virtuale, ma abbia a sua volta posato dei*

COMMENTEDIBBBBBBNO(88\$)ppotpart&wzannr00022990d&l16900420225eat.44

*“La norma ha introdotto l’occupazione mediata del territorio che richiede una relazione materiale con la cosa che deve essere mediata dalla infrastruttura del concessionario. La norma sopra indicata fa riferimento quindi all’utilizzo di infrastrutture materiali del concessionario di cui l’occupante mediato abbia la disponibilità. Nel caso di specie Vodafone non occupa e non usa la rete Tim e comunque **non ha alcuna relazione materiale con gli impianti** presenti nel territorio di Umbertide”.*

*“la dizione normativa postula ... un rapporto di utilizzazione materiale delle infrastrutture, da parte di soggetto diverso dal concessionario (nel caso di specie, TIM), il che implica però, se si vuol dare un senso al nomen iuris adottato dal legislatore, la fruizione, effettiva, da parte di soggetto altro, rispetto al concessionario, dei manufatti da quest’ultimo collocati e posti in opera. **Nel caso in esame, sussiste un rapporto meramente virtuale** tra la impiantistica TIM, sita in Castello D’Annone, e punti di raccolta Vodafone, situati altrove, il che esclude la applicabilità della norma”*

*“l'imposizione del pagamento del Canone sia al concessionario proprietario delle infrastrutture, sia al loro utilizzatore, comporterebbe la duplicazione del pagamento del Canone Unico, in relazione ad un medesimo ed unico episodio di occupazione. ... il caso in esame è pienamente riconducibile al perimetro applicativo della norma sopra riportata, atteso che TIM è proprietaria di infrastrutture e in quanto tale titolare di atto di concessione concluso con il Comune di Adria, mentre Vodafone, sulla scorta di rapporti contrattuali intrattenuti con TIM, è mero titolare dei contratti di vendita di un bene che viene distribuito esclusivamente dalle infrastrutture di TIM”.*

\* \* \*

**IN VIA SUBORDINATA: MANCANZA DI FORMALE CONTESTAZIONE.**

COMMENTEDIBBBBBBNO(88\$)pootpartemzannr00028900de1169042025eat.44

Si è già detto, ed è espressamente riconosciuto nel provvedimento impugnato, che Vodafone non è titolare di alcuna concessione di suolo pubblico nel territorio di Berbenno, né è tenuta a richiedere tale concessione.

Nessuna delle due evenienze si verifica nel caso di specie. Infatti, ammesso e non concesso che possa parlarsi di “occupazione”, l’occupante di fatto (abusivo) è soggetto passivo solo in mancanza di un titolare della concessione, che in questo caso esiste certamente.

Ad ogni modo, a mente dell'art. 36, comma 1, del citato Regolamento, le “occupazioni realizzate senza la concessione ... sono considerate abusive” e, come stabilito dal comma successivo “in tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative”.

Ne deriva, da un lato, la conferma che in tutti i casi di occupazione vi deve essere una materialità, ossia una modificazione della realtà, riguardante un'area che non sia già attribuita in concessione.

Ne deriva, inoltre e per quanto qui rileva, che la pretesa recuperatoria nei confronti di soggetto che non sia titolare di concessione deve essere sempre preceduta da un verbale di accertamento (ad opera della Polizia locale o dell'agente accertatore), circostanza che nel caso di specie non si è verificata.

Di qui un ulteriore vizio del provvedimento impugnato.

\* \* \*

#### (IV)

**IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: ILLEGITTIMA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE DA OMESSO VERSAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 58 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL CANONE PATRIMONIALE.**

In via ulteriormente subordinata, va contestata la quantificazione della sanzione comminata.

Come detto, il Comune di Berbenno ha ritenuto di applicare, per l'omesso versamento del canone, una “*sanzione amministrativa pecuniaria*” definita “*nella misura del 100% dell'importo dovuto*”.

Pertanto, la sanzione applicata (€ 3.484,43) è pari alla somma dei canoni pretesi per ciascuna delle quattro annualità richieste (€ 800,00 + € 830,40 + € 924,24 + € 929,79 = € 3.484,43).

La misura della sanzione è tuttavia illegittima, considerato che il Regolamento Comunale di Berbenno (**doc. 16**) che disciplina il canone patrimoniale di occupazione, all'**art. 58**, rubricato “*Sanzioni*” stabilisce inequivocabilmente che “... **sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre gli interessi legali**”.

Ne deriva che la sanzione è stata erroneamente quantificata in misura pari al canone asseritamente omesso (€ 3.484,43) anziché nella misura del 30% del

canone asseritamente omesso, ossia € 1.045,32.

Pertanto, il Comune, pur avendo espressamente disciplinato la misura della sanzione, in virtù del proprio potere regolamentare conferito dalla Legge e che può spingersi fino alla istituzione di esenzioni e riduzioni, ha apertamente violato l'art. 58 del proprio Regolamento, senza giustificazione alcuna.

Di qui, un ulteriore motivo di annullamento dell'avviso impugnato.

\* \* \* \* \*

Per tutte le ragioni sopra esposte, e, comunque per quelle di giustizia, e con ogni più ampia riserva di ulteriormente eccepire, dedurre, produrre e di formulare conclusioni integrative e istanze, anche istruttorie, nei termini di rito, la Vodafone Italia S.p.A., come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

#### **CITA**

il **COMUNE DI BERBENNO** (C.F. 00313890162), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Via Europa n. 7 – 016023 Berbenno (BG), PEC [comuneberbenno@legalmail.it](mailto:comuneberbenno@legalmail.it) (estratta da Registro IPA), a comparire avanti al Tribunale di Bergamo, Sezione e Giudice designandi all'udienza che sarà tenuta il **29 settembre 2025**, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite all'art. 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'articolo 168-*bis* c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. Avverte inoltre che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che la mancata comparizione alla suindicata udienza comporterà la prosecuzione del processo in sua dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti



## CONCLUSIONI

Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, disattese eventuali contrarie istanze ed eccezioni, accertato che Vodafone non è concessionario dell'infrastruttura di rete sita su territorio comunale e che non ha l'utilizzo materiale della stessa, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, in tutto in parte, l'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 6.02.2025 emesso dal Comune di Berbenno, e ogni altro atto o avviso ad esso connesso o consequenziale, in quanto illegittimi per difetto dei presupposti in fatto e in diritto. Conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla Vodafone Italia S.p.A. al Comune di Berbenno per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024 a titolo di canone unico patrimoniale, indennità, interessi e, comunque, a titolo di sanzioni; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.

In via istruttoria, si producono, oltre all'originale notificato del presente atto di citazione, i seguenti documenti in copia: **A)** Procura notarile Vodafone/Lindam S.r.l. del 15.1.2019; **1)** Avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 6.02.2025; **2)** Notifica pec avviso di accertamento; **3)** Istanza di autotutela Vodafone 4.3.2025; **4)** Nota prot. 1910 del 13.3.2025 del Comune; **5)** Brochure TIM per servizi NGA; **6)** Dossier Senato conversione DL 146/2021; **7)** Emendamenti al D.L. 228/2021 non approvati; **8)** Trib. Vicenza, sent. 21.1.2025; **9)** Trib. Padova sent. 20.9.2023; **10)** Trib. Padova sent. 2.1.2024; **11)** Trib. Perugia, sent. 5.7.2024; **12)** Trib. La Spezia, sent. 21 marzo 2025; **13)** Trib. Perugia, sent. 18 marzo 2025; **14)** Trib. Asti, sent. 12 marzo 2025; **15)** Trib. Rovigo, sent. 10 marzo 2025; **16)** Regolamento Com. Berbenno sul Canone Patrimoniale di Occupazione.

*Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa ammonta ad € 7.173,00 e che pertanto il contributo unificato è dovuto e sarà anticipato nella misura di € 237,00, oltre diritti di cancelleria.*

Roma, 16 aprile 2025

Avv. Paolo Caruso